

1502122-18.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... possibilidade de redução da pena do tráfico, mas em 1/6, sem sua substituição nos termos do art. 44 do CP, a cumprida em regime semiaberto, sem apelo em liberdade, e sim com a perda do numerário apreendido nos autos.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória no tráfico e pela atipicidade no que tange à resistência. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502122-18.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502122-18.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2294502/2021 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 2294502 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 97/21/301 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Lopes da Silva Junior

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

VISTOS.

EDSON LOPES DA SILVA JUNIOR, qualificado às fls. 05 e 07/08, está sendo processado como incurso artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 329, caput, do Código Penal, combinados na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 15h00, na Rua José Vicente, altura do nº 153, bairro do Inamar, nesta cidade de Diadema, nas proximidades da Escola Municipal de Educação Básica Carolina Maria de Jesus, trazia com ele, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 34 embalagens plásticas contendo 22,1g da droga cocaína, 28 embalagens plásticas contendo 13,36g da mesma droga, na forma de crack, e 69

embalagens plásticas contendo 94,96g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 20/21 e laudo de constatação provisória de fls. 27/29, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, EDSON LOPES DA SILVA JUNIOR opôs-se à execução de ato legal mediante violência física contra o policial civil André Hidalgo, funcionário público estadual competente para executá-lo.

A denúncia foi recebida em 11/11/2021 (fl.64), sem proposta de transação penal ante a gravidade delitativa. Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl.39/42), seguiu-se com a citação do réu 89, a quem foi nomeado Defensor Público que ofertou defesa inicial as fls.105/106.

Em audiência uma foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas Partes, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que as penas base devam ser fixadas acima do mínimo legal diante da excessiva quantidade e variedade de drogas altamente nocivas como o crack e cocaína, e por mais de uma resistência por parte do réu, com possibilidade de redução da pena do tráfico, mas em 1/6, sem sua substituição nos termos do art. 44 do CP, a cumprida em regime semiaberto, sem apelo em liberdade, e sim com a perda do numerário apreendido nos autos.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória no tráfico e pela atipicidade no que tange à resistência.

Subsidiariamente, requereu que as penas-base fossem fixadas no mínimo legal, com a atenuante da confissão, com o redutor máximo da pena do tráfico, fixando-se regime mais brando e substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, com direito de apelo em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de exibição e apreensão de fls.20/21, laudo de constatação e definitivo, ambos positivos para as drogas maconha e cocaína (respectivamente às fls. 27/29 e 73/75) além da apreensão de numerário proveniente da mercancia ilícita (R\$42,00 - fl.20), e das anotações da contabilidade do tráfico (laudo pericial as fls. 102/104).

A autoria é incontestada conforme prova que sigo analisando.

Os policiais civis afirmaram em solo pré-processual (fls.3/4) que com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, diligenciaram com uma viatura descaracterizada até a Rua José Vicente, próximo ao número 153, Jardim Inamar, Diadema/SP, praticamente ao lado da EMEB Carolina Maria de Jesus (escola de educação básica), conhecido local de traficância de drogas, onde puderam visualizar um indivíduo de camiseta azul e uma calça de taktel preta mexendo em um matinho exatamente onde costuma ficar o "VAPOR" (indivíduo responsável pela venda da droga), então decidiram por abordá-los. Iniciada a abordagem, o indivíduo tentou correr, quando foi segurado. Nesse momento o mesmo se voltou contra o policial André dando socos, iniciando uma briga (vias de fato), e com a ajuda do policial Walter, conseguiram derrubar o indivíduo no chão e contê-lo com o uso de algema. Contido, o indivíduo foi identificado como sendo EDSON LOPES DA SILVA JUNIOR. Em busca pessoal, verificou-se que o mesmo estava com duas calças e uma bermuda avermelhada, nos seus bolsos foram localizados 2 invólucros de substância assemelhada a COCAÍNA e um invólucro de substância assemelhada a MACONHA, o valor de R\$ 42,00 em espécie, e um pequeno papel com anotações do tráfico de drogas. Ao verificarem o local onde viram o indivíduo

mexer, foi localizado um pequeno saco plástico com vários outros invólucros de substâncias assemelhadas a COCAÍNA, CRACK e MACONHA, sendo então imediatamente exarada voz de prisão ao mesmo pelo crime de tráfico de drogas e junto das substâncias foi conduzido até esta unidade.

Em juízo o policial André Hidalgo reiterou que no dia o réu estava traficando num escadão próximo a uma escola. Estava numa viatura descaracterizada e no dia deixou o parceiro na parte de baixo e subiu para a parte de cima, e assim que chegou já avistou o réu com um saco de drogas na mão e um tipo de fila com três pessoas para adquirirem o entorpecente com ele, quem não percebeu sua chegada, achando que seria mais um usuário, e assim conseguiu detê-lo e seu parceiro o auxiliou. O réu começou a se debater com socos. Teve que usar força moderada para contê-lo. Os usuários correram. Dentro da sacola estavam as drogas e dinheiro. Algemado, foram até a viatura, e ao embarcá-lo no bando de trás, a porta estava sem a trava de criança, e daí o réu esperou fechar a porta e logo a abriu, e ao olhar, viu que ele correu entre umas vielas. Se separaram para fazer outro cerco. Tanto o réu como o policial André caíram nessa corrida. Ele foi perdido de vista por um tempinho até ser localizado num campinho cerca de um quilômetro de distância, onde foi preso. Reconhece o réu. O local é um ponto de venda de drogas conhecido e foi a primeira vez que o viu no local. A distância é de uns dez a quinze metros entre a escola e a biqueira.

Neste sentido foi o depoimento do policial Walter Silveira alegou que se trata de um escadão já conhecido como ponto de venda de drogas. Separaram-se. Ficou na parte de baixo. Havia uma fila para comprar drogas. André chegou primeiro. Teve que auxiliá-lo a algemar o réu. Foram até a viatura descaracterizada. Ao colocarem o réu dentro da viatura, o réu destravou a porta e fugiu, mesmo algemado. O policial André conseguiu pegá-lo. O réu machucou o policial André, pois ele criou uma resistência ao ser algemado, dava empurrões. Criou tumulto. Localizaram uma anotação de drogas, uma porção de dinheiro, e com o réu havia drogas e mais destas numa sacolinha. O local é bem próximo de uma escola, na calçada desta. Acredita que André se machucou ao cair no chão ao perseguir o réu, embora o réu tenha dado chutes e empurrões contra eles quando contido na primeira vez.

O réu, extrajudicialmente (fl.05), respondeu que está desempregado há mais de três meses e que está passando por necessidade na sua casa, razão pela qual aceitou trabalhar vendendo drogas e tem feito isso desde então. Que ficaria naquele local das 08 às 20 horas e receberia ao final do seu turno o valor de R\$ 200,00. Nos dias de semana a biqueira costuma arrecadar o valor de R\$ 900,00 por turno, valor este que é recolhido no decorrer do turno, em horários alternados, sem previsão. Vendia a unidade do invólucro de maconha por R\$ 5,00, a unidade do invólucro de K2 (espécie diversa de maconha) por R\$ 5,00, a unidade do invólucro de cocaína por R\$ 10,00 e a unidade do invólucro de crack por R\$ 5,00. Estava na biqueira quando percebeu a aproximação policial e tentou correr, porém um policial o segurou, então se voltou contra ele, entrando em luta corporal com o mesmo visando fugir do local, porém foi contido. No interior da viatura, mesmo algemado, conseguiu abrir a porta, saltar do veículo e correr, sendo contido novamente pelos policiais e colocado novamente na viatura e trazido até esta delegacia. Declarou que não tem passagem criminal depois que atingiu a maioridade, porém quando menor, foi apreendido por roubo.

Sob o crivo do contraditório o acusado alegou não se lembrar muito dos fatos porque estava drogado. Foi a primeira vez. Não tem passagem policial, só quando adolescente, por crime equiparado ao roubo. O dinheiro apreendido nos autos era de vendas de drogas que fizera. E as anotações também eram suas. O local fica quase do lado de uma escola, e os alunos, ainda que poucos, podiam usar o escadão para chegarem na escola.

Logo, o interrogatório com a confissão do réu não é prova única, pois veio

corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária.

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Presenciado ato de comércio, e ainda, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. Ademais, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível à demonstrá-lo, o encaminhamento de testemunha civil presencial, ou seja, comprador/usuário.

Afasto tese de estado de necessidade, de situação de pobreza, ou falta de emprego como alegado pelo réu em solo extrajudicial, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ademais, admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas, o que não é aceitável. Não bastasse isso, já se decidiu no sentido de que: (...) Não há prova suficiente nos autos de que o réu passasse por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar e lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

Assim como não procede a tese de se tratar de mero usuário, posto que não demonstrado cabalmente como lhe competia o ônus dessa prova. Ademais, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína/crack), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 20), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável no que tange ao crime de tráfico de entorpecentes.

Assim como ocorre no que diz respeito à causa de aumento de pena pelo tráfico se dar nas imediações de estabelecimento de ensino. Como visto acima, o acusado traficava as drogas na mesma calçada onde fica uma escola, cerca de dez metros distante, sendo local de passagem para alunos daquela escola, que vem do escadão, por ser esse o atual entendimento do e. STJ, no sentido da prescindibilidade do intuito do traficante em atingir especificamente os alunos que ali estudam. Vide: (...) 4. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o

público específico dos locais referidos na norma. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 690.916/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

E no que tange ao delito de resistência, como visto, restou incontroverso que o réu reagiu à prisão, entrando em vias de fato com o policial André, o chutando e empurrando, tanto que o policial ficou machucado, como se vê do laudo pericial de fl. 72. E não bastasse isso, já preso e algemado, colocado dentro da viatura policial, o réu abriu a porta que estava sem a trava de segurança, e desembarcou do veículo, logrando fuga, sendo perseguido e detido novamente pelo policial André, cerca de um quilômetro distante, o que não deixa dúvida de sua oposição à execução de ato legal. Dito isso, ve-se tratar-se na presente hipótese, de resistência ativa, consiste justamente no emprego de violência, de emprego de energia física (vis corporalis) contra funcionário público, servindo para configurar o crime, ainda que se alegue terem sido as lesões corporais de natureza leve encontradas no policial André, proveniente da própria queda, o que não afasta a conduta anterior do acusado.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito de resistência onde o réu além de empurrar e chutar e machucar um dos policiais, ainda fugiu de dentro da viatura policial, estando já algemado, e passou a correr por dentro da comunidade, cerca de um quilômetro, com o policial atrás, gerando risco aos transeuntes, até da arma cair e haver um disparo acidental, tudo a indicar maior audácia e periculosidade que chega a beirar ação cinematográfica, e no que concerne ao delito de tráfico, principalmente pela grande quantidade de narcótico apreendido (131 no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, as penas base acima dos mínimos legais, qual seja, para este crime em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, e em 02 meses e 10 dias de detenção pela resistência.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, e sim a atenuante da confissão espontânea a reduzir as duas penas ao mínimo legal (em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, e em 02 meses de detenção). Ora, o réu confessou o tráfico em juízo, e em solo policial já havia confessado ter se oposto à prisão como se vê a fl. 05, o que não negou hoje, e tendo me valido dessa prova a também embasar a condenação, por questão de justiça ora a acolho como atenuante.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento nem de redução da reprimenda para a resistência. Mas sim para ao tráfico. Dito isso, aumento a pena em 1/6 por ter esse crime ocorrido nas imediações de uma escola, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão mais 583 dias-multa. E a reduzo pelo previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, fazendo jus o sentenciado ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls. 60), embora conte com uma apreensão por roubo (fl. 60) a indicar que o crime em tela não se tratou de um fato isolado em sua vida. Some-se a isso os tipos/natureza das drogas, especialmente a cocaína e o crack, de maior nocividade, alto poder viciante e degradante da saúde do ser humano, somado à apreensão de numerário a indicar que vendas foram efetivamente feitas à usuários, disseminado e contribuído para o vício, além de estar o réu em poder de anotação típica da contabilidade do tráfico, por todos esses motivos a indicarem maior envolvimento com o crime e com a mercancia ilícita, opto pelo percentual de 1/6 a reduzir a reprimenda para 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Somo as penas (art. 69 do CP) que totalizam 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mais 02 meses de detenção, mais o pagamento de 485 dias-multa.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por não se mostrar socialmente recomendável,

tratando-se de uma ação de extrema gravidade, já não bastasse a ausência de requisito objetivo (pena supera os quatro anos máximos permitidos em lei).

No mais, segue jurisprudência nesses moldes : ... O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010).

Fixo o regime prisional aberto para o delito apenado com detenção, e o semiaberto para o tráfico, por conta da grande quantidade e variedade das drogas e pelo fato do réu já ter sido apreendido por roubo quando adolescente infrator, sofrendo medida sócio educativa, a indicar que o delito em tela não se tratou de um fato isolado em sua vida, e principalmente pela quantidade de pena não permitir regime mais brando, já que ultrapassa quatro anos. Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, sem direito à progressão de regime, considerando a prisão do réu por menos de cinco meses.

Ressalto o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o acusado, ora condenado a regime que o manterá preso para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva, considerando ainda . (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dj. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dj. 20.03.2013).

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado, mas sim determinada a perda do dinheiro apreendido por ser produto do crime, como visto.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra EDSON LOPES DA SILVA JUNIOR, qualificado às fls. 05 e 07/08, como incurso artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 329, caput, do Código Penal, combinados na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 02 meses de detenção em regime aberto, mais ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a assistência pela DPE.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 20), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a incineração de todos os entorpecentes.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias, sob as pena da lei.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA